

2026년 9월 14일

수 신 : 권선 113-6 구역 주택재개발정비사업조합

참 조 : 종교용지 임시이사회

제 목 : 법률 의견 송부(Our ref: K1874C1, 표지 포함 : 29 면)

귀 조합의 2026. 7. 24.자 질의(관리처분계획의 적법성 등 검토)에 대하여 검토를
마치고 별첨과 같은 법률 의견을 송부하오니, 업무에 참고하시고 의문이 있으시면
언제든지 연락하여 주시기 바랍니다.

별 첨 : 의 건 서

법무법인(유한) 광장 (Lee & Ko)

변호사 장 성 원



변호사 추 강 철



변호사 김 진 훈



변호사 김 진 홍



변호사 구 민 채



검토의견 요약

본건에 관한 저희 검토 의견을 간략하게 요약하면 다음과 같습니다. 보다 자세한 내용은 의견서 본문을 참고하시기 바랍니다.

● 검토 의견

1. 조합원이 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니하면 분양신청기간 종료일 다음 날에 현금청산대상자가 되고, 대통합의는 현금청산대상자에 대한 손실보상 협의에 해당합니다. 따라서 귀 조합이 대통합의를 체결한 각 종교재단이 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 이상 위 각 종교재단은 대토부지 소유권이전 여부와 상관 없이 현금청산대상자로 보아야 합니다.

2. 비례율 산정 시 포함되는 종전자산평가액에는 분양대상자의 종전자산평가액만 포함되어야 하므로, 현금청산대상자인 종교재단의 종전자산평가액이 포함되어 비례율이 산정된 것은 일응 관리처분계획의 하자를 구성할 수 있으나, 그러한 하자가 중대하거나 명백하다고 보기는 어렵습니다. 따라서 귀 조합의 관리처분계획이 무효라고 판단될 가능성은 높지 아니할 것으로 판단됩니다(즉 관리처분계획이 적법하다고 보기는 어려우나 여전히 유효한 것으로 판단될 가능성이 높아 보입니다).

귀 조합이 관리처분계획 중 비례율에 관한 하자를 치유하기 위해서는 관리처분변경 계획에 관한 조합원 총회 결의를 득하고, 변경된 관리처분계획에 관한 관리처분계획변경인가를 득하여야 할 것으로 보이며, 이전고시 이전에 관리처분계획 변경 절차를 거치는 것이 보다 안전할 것으로 사료됩니다.

3. 귀 조합이 현금청산대상자로 되어 조합원 지위를 상실한 종교재단의 대리인을 조합장으로 선임한 총회 결의는 무효로 판단되고, 다만 도시정비법 제43조 제2항, 제3항에 따라 조합장은 당연 퇴임하되 퇴임 전에 관여한 행위는 유효한 것으로 판단될 가능성이 있습니다.

다만, 분쟁의 소지를 없애기 위해 귀 조합은 적법한 직무대행자 또는 새로이 선임된 조합장이 소집한 총회에서 기존 결의 및 계약에 대한 추인 결의를 해 두는 것이 안전한 방안이 될 것으로 판단됩니다.

의견서

I. 사안의 개요 및 질의의 요지

권선 113-6 구역 주택재개발정비사업조합(이하 ‘귀 조합’이라고 합니다)은 수원시 권선구 세류동 817-72 번지 일원(이하 ‘이 사건 사업구역’이라 합니다)에서 「도시 및 주거환경 정비법」(이하 ‘도시정비법’이라고 합니다)에 따른 재개발사업(이하 ‘이 사건 사업’이라고 합니다)을 시행하고 있습니다.

귀 조합은 2012 년 내지 2013 년경 이 사건 사업구역 내 종교시설을 소유하고 있던 재단법인 기독교대한감리회유지재단 및 재단법인 천주교수원교구유지재단¹(이하 통칭하여 ‘이 사건 각 종교재단’이라 합니다)과 사이에 ‘이 사건 각 종교재단은 자신이 소유하고 있는 종교용지를 귀 조합에게 제공하고, 귀 조합은 대토부지 및 보상금을 제공’하기로 하는 대토합의(이하 ‘이 사건 각 대토합의’라고 합니다)를 체결하였으며, 이 사건 각 종교재단은 2017. 2. 1. ~ 2017. 3. 20. 사이에 진행된 분양신청기간 당시 분양신청을 하지 아니하였습니다.

이후 귀 조합은 2018. 6. 8. 최초 관리처분계획인가를 득하였는데, 해당 관리처분계획상 ‘분양대상자의 종전자산’에는 이 사건 각 종교재단이 소유하고 있던 종교용지가 포함되었고, 이를 전제로 관리처분계획의 비례율이 산정되었으며, 현재까지 종교용지가 종전자산에 포함된다는 전제 하에 관리처분계획이 변경되어 왔습니다.

한편, 기독교대한감리회유지재단의 대리인은 2024. 12. 2. 조합장에 당선되어 직무를 수행하였습니다.

이러한 상황에서, 귀 조합은 다음의 사항을 질의하셨습니다.

1. 이 사건 각 종교재단이 현금청산대상자에 해당하는지 여부
2. 이 사건 각 종교재단이 소유한 종교용지의 가액을 종전자산평가액에 포함하여 비례율을 산정하고 관리처분계획을 수립한 것이 적법한지 여부 및 하자 치유방안

¹ 이하 각 재단의 명칭에서 재단법인을 생략합니다.

3. 귀 조합의 조합장 선임이 적법한지 여부 및 하자 치유방안

II. 검토 의견

1. 질의 1.에 관하여 – 각 종교재단이 현금청산대상자에 해당하는지 여부

가. 분양신청을 하지 아니한 조합원의 지위

분양신청기간 당시 시행되던 구 도시정비법(법률 제 13782 호, 2016. 9. 1. 시행된 것; 이하 ‘구 도시정비법’이라 합니다) 제 46 조 제 2 항은 “대지 또는 건축물에 대한 분양을 받고자 하는 토지등소유자는 제 1 항의 규정에 의한 **분양신청기간 이내에** 대통령령이 정하는 방법 및 절차에 의하여 **사업시행자에게 대지 또는 건축물에 대한 분양신청을 하여야 한다.**”고 규정하고 있으므로, 조합원은 귀 조합이 공고한 분양신청기간 내에 분양신청을 하여야 합니다.

분양신청을 하지 아니한 조합원에 대하여, 구 도시정비법 제47조 제1항은 “사업시행자는 **분양신청을 하지 아니한 자**, 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자 또는 제 48 조에 따라 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자에 대해서는 **관리처분계획 인가를 받은 날의 다음 날로부터 90 일 이내에** 대통령령으로 정하는 절차에 따라 토지·건축물 또는 그 밖의 권리에 대하여 **현금으로 청산하여야 한다.**”고 규정하고 있는바, 귀 조합의 조합원 중 분양신청을 하지 아니한 자는 현금청산대상자에 해당하게 됩니다.

이와 관련하여, 대법원은 “**주택재개발정비사업조합의 조합원이 분양신청절차에서 분양신청을 하지 않으면 분양신청기간 종료일 다음 날에 현금청산대상자가 되고 조합원의 지위를 상실한다**”고 일관되게 판시하고 있습니다(대법원 2021.2.10. 선고 2020 두 48031 판결, 대법원 2011.7.28. 선고 2008 다 91364 판결 참조).

따라서 **조합원인 토지등소유자가 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니할 경우에는 분양신청기간 종료일 다음 날에 현금청산대상자**가 되고, 더 이상 조합원에 해당하지 아니하게 됩니다.

나. 대도합의를 체결한 조합원도 현금청산대상자에 해당하는지 여부

1) 재개발사업의 경우 분양대상자에게 신축 건축물 및 그에 대한 대지를 분양하는 것이 원칙적인 방식이고, 특정 조합원과의 사이에 개별적으로 합의하여 대체 토지를 제공하고 건축비, 이사비 등의 현금보상을 병행하는 이른바 ‘대토보상의 방식’은 구 도시정비법에서 예정한 분양방식으로 볼 수는 없습니다. 다만, 이와 같은 ‘대토보상의 방식’은 정비사업구역 내에 대체 부지를 확보하여야 할 개별적인 특수성이나 필요가 있는 때에 실무상 예외적으로 활용되고 있습니다.

구체적으로, 조합원이 분양신청을 한 경우에는 조합원 분양 절차에 따라 종후자산을 분배 받게 되는데, 이때 조합원은 종전자산 평가액과 종후자산 평가액의 차액을 분담금으로 납부하는 방식으로 종후자산에 해당하는 신축 아파트 또는 상가 등을 공급받게 됩니다.

반면, 분양신청 기간 내에 분양신청을 하지 않아 조합원의 지위를 상실한 현금청산대상자에 대한 손실보상에 관해서는 구 도시정비법 제 40 조 제 1 항에서 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 (이하 ‘토지보상법’이라 한다)을 준용함으로써, 토지보상법이 정하는 수용에 의한 보상을 받을 수 있는 절차를 마련하고 있습니다.

즉 토지보상법 제63조 제1항은 손실보상에 관하여 현금보상을 원칙으로 하면서도, 예외적으로 공익사업의 시행으로 조성한 토지로 보상(현물보상)할 수 있는 경우를 규정하고 있고, 구 도시정비법 제 40 조 제 4 항 또한 도시정비법상 손실보상의 한 방법으로 현물보상이 가능하다는 전제에서 “대지 또는 건축물을 현물보상하는 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제 42 조에도 불구하고 제 52 조에 따른 준공인가 이후에도 할 수 있다.”라고 규정하고 있습니다. 도시정비법상 현금청산대상자에 대한 손실보상은 위와 같은 근거 규정에 따라 현금보상 뿐만 아니라 대토보상과 같은 현물보상 방식으로 이루어지게 되는 것입니다.

이처럼 도시정비법의 체계상 ‘분양신청을 통한 조합원 분양 절차’와 ‘분양신청을 하지 않음으로써 현금청산대상자가 됨에 따른 손실보상 절차’는 명확하게 준별되는바, ‘대토합의’는 추가 분담금 납부를 예정하지 않는 현물보상에 관한 합의이므로, 이는 현금청산대상자에 대한 손실보상 협의에 해당하는 것입니다.

이러한 견지에서, 부산지방법원 2020. 5. 14. 선고 2019 구합 22430 판결은 “재개발사업의 경우 분양대상자에게 신축 건축물 및 그에 대한 대지를 분양하는 것이 원칙적인 방식이고, **특정 조합원과의 사이에 개별적으로 합의하여 대체 토지를 제공하고 건축비, 이사비 등의 현금보상을 병행하는 방식은 구 도시정비법에서 예정한 분양방식으로 볼 수는 없다.**”고 실시하여 종교시설과 조합의 대토합의는 도시정비법에서 예정한 분양방식이라고 볼 수 없으며, 별도의 손실보상에 관한 합의에 해당한다고 판단한 바 있습니다.

따라서 대토합의는 현금청산대상자에 대한 손실보상 합의에 해당하는 것으로 보아야 하고, 그에 따라 대토합의를 체결한 조합원이라고 하더라도 **분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 이상 현금청산대상자에 해당합니다.**

2) 이에 다수의 하급심 판결에서는 대토합의를 체결하였거나 대토합의에 관한 합의를 진행 중이었던 조합원이라고 하더라도, **분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 이상 현금청산대상자에 해당하게 된다**고 판단한 바 있습니다.

- ① 서울고등법원 2017. 7. 12. 선고 2017 나 2013616 판결(확정)은 “도시정비법 제 46 조 제 1 항, 제 47 조 제 1 항의 규정을 종합하여 보면 사업구역 내의 토지등소유자가 사업시행자가 정한 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 경우 사업시행자는 관리처분계획 인가를 받은 다음날부터 90 일 이내에 토지, 건축물 등에 대하여 현금으로 청산하여야 하는 것인바, 피고 교회가 원고가 정한 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 원고로서는 피고 교회 소유의 이 사건 각 부동산에 대하여 현금으로 청산할 의무가 있다고 할 것이고, 피고들의 주장과 같이 피고 교회와 원고가 피고 교회가 사업구역 내의 토지를 분양받는 것을 전제로 분양받는 토지의 위치 및 건물보상비에 대한 협상을 진행하여 왔다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 피고 교회가, 주택재개발사업의 진행과 관련한 다수의 이해관계인들의 권리, 의무를 명확하게 확정하기 위하여, 분양신청기간 및 분양신청기간 내에 분양을 신청을 하지 아니한 경우를 정한 도시정비법 제 46 조, 제 47 조의 규정의 적용을 받지 않는다고 볼 수는 없으므로, 이와 다른 전제에서 피고 교회가 현금청산대상자가 아니라는 피고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.”라고 판단한 바 있습니다.

- ② 서울행정법원 2020. 1. 10. 선고 2017구합87463 판결은 「주택재개발정비사업조합이 종교시설 소유자와 종교부지에 관한 합의를 작성한 다음, 주택재개발정비사업조합이 종교시설 소유자를 현금청산대상자로 분류하는 내용의 관리처분계획을 수립한 사안」에서, “참가인은 두 차례에 걸쳐 원고들을 대상으로 분양신청기간을 정하여 분양신청통지를 함으로써 구 도시정비법령에 따른 분양신청통지의무를 적법하게 이행하였고, 원고들이 위 각 기간 내에 모두 분양신청을 하지 않았음은 앞서 본 바와 같으므로 이로써 원고들은 위 법 제47조에 의하여 현금청산대상자가 됨과 동시에 참가인의 조합원 지위를 상실하였다.”고 판단하였습니다.
- ③ 대전지방법원 2022. 12. 22. 선고 2022 카합 50526 결정도 “채무자들은 '채무자 유지재단은 이 사건 사업의 사업시행구역 내에 토지소유자에 대하여 이 사건 조합의 조합원이다'는 취지로 주장하나, 채무자 유지재단은 채권자에 분양신청을 하지 않았고, 도시정비법에 따르면 토지 등 소유자가 소유하는 부동산의 종류가 어떠한 특성을 가지는지 관계없이 토지 등 소유자에게 동일한 절차를 보장하고 있으므로 채무자가 분양신청을 하지 않았다면 채무자는 채권자의 조합원이 될 수 없다.”고 판단하여 교회 재단이 대토 등에 관한 협의를 진행한 사정이 있을 뿐 분양신청을 하지 아니한 경우에는 조합원으로 볼 수 없고, 현금청산대상자로 봄이 타당하다는 취지로 판단한 바 있습니다.

다. 소결론 - 이 사건 각 종교재단의 법적지위(현금청산대상자)

이상의 법리를 종합하면, 이 사건 각 종교재단이 이 사건 각 대토합의를 체결하였다는 사정만으로는 이 사건 각 종교재단이 분양신청을 하지 않고도 조합원의 지위를 유지한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 각 종교재단은 현금청산대상자에 해당하고, 분양대상자인 조합원에 해당하지 아니합니다.

즉 이 사건 각 종교재단은 2017.2.1.부터 2017.3.20. 사이에 진행된 분양신청기간 종료일 다음 날부터 조합원 지위를 상실하고 현금청산대상자의 지위에 있게 되었으며, 현재 대토대상 부지의 소유권이 각 종교재단에게 이전되지 않았다는 사정은 위와 같은 지위에 영향을 미치지 않는다고 할 것입니다(앞서 본 바와 같이 구 도시정비법 제 40 조 제 4 항은 대토부지 제공에 관한 현물보상은

준공인가 이후에 할 수 있다고 규정하고 있으므로, 대토부지 소유권 이전 여부는 현물보상을 이행하였는지 여부에만 관련이 있는 것이고, 현금청산대상자의 지위에 직접적인 영향을 미치지 아니합니다).

2. 질의 2.에 관하여 – 관리처분계획의 적법성 여부 및 하자 치유방안 검토

가. 관리처분계획상 비례율 산정의 하자 존재 여부

도시정비법 시행규칙 제 7 조 제 3 항 및 [별지] 제 4 호 서식의 조합설립동의서에 따르면, 분양대상자별 분담금 및 그를 산정하기 위한 비례율은 아래와 같이 산정됩니다.

분양대상자별 분담금 추산액 = 분양예정인 대지 및 건축물의 추산액 - (분양대상자별 종전의 토지 및 건축물의 가격 × 비례율*)

* **비례율** = (사업완료 후의 대지 및 건축물의 총 수입 - 총사업비) / 종전의 토지 및 건축물의 총 가액

이처럼 정비사업의 비례율은 신축 아파트를 분양 받게 됨에 따라 청산금 부담의무를 지게 되는 조합원들의 분담금을 추산하기 위하여 산정되는 것이므로, 정비사업에 따른 총 수입에서 총 비용을 제외한 후, 이를 **분양대상자의 종전 자산의 총 가액**을 나눈 값에 100(%)를 곱하여 산정되는 것입니다.

그런데 현금청산대상자는 분양대상자인 조합원에 해당하지 아니하므로, 현금청산대상자의 종전의 토지 및 건물의 총 가액은 총 사업비의 측면에서만 고려되어야 하는 것이고, 비례율 산식의 분모인 ‘종전의 토지 및 건축물의 총 가액’에 고려될 수 없습니다.

이러한 견지에서, 서울고등법원 2019. 2. 14. 선고 2018 누 55427 판결은 “비례율 산정의 기준이 되는 ‘종전의 토지 및 건축물의 총 가액’에는 현금청산자를 제외한 조합원 소유의 종전 토지 및 건축물의 가액만이 포함된다.”고 판단한 바 있습니다.

앞서 살펴본 바와 같이, 이 사건 각 종교재단은 현금청산대상자에 해당하므로, 분양신청기간 종료일 다음 날부터는 조합원의 지위를 상실하게 되고, 분양대상자에 해당한다고 볼 수 없습니다. 따라서 비례율 산정의 분모가 되는 ‘**분양**

대상자의 종전 토지 및 건축물의 총 가액에는 이 사건 각 종교재단이 소유하고 있던 종교용지가 포함될 수 없는 것이고, 그와 같이 비례율이 잘못 산정되었다면 이는 관리처분계획의 하자를 일응 구성하게 될 것으로 판단됩니다.

다만, 관리처분계획에 어떠한 하자가 있다고 하여 곧바로 효력을 상실하는 것은 아니고, 법원 판결에 의해 취소되거나 무효확인을 받는 경우에만 그 효력이 상실될 수 있는데, 현재 최초 관리처분계획에 대한 취소소송은 제소기한²이 도과하여 제기될 수 없고, 오로지 무효확인 소송만 제기될 수 있습니다.

이러한 무효확인 소송의 경우에는 행정처분(관리처분계획)에 하자가 인정되더라도 그러한 하자가 중대하고 명백한 경우에만 해당 행정처분이 무효로 판단될 수 있는바, 이하에서는 귀 조합의 관리처분계획이 무효로 판단될 수 있는지 여부에 관해 먼저 살펴보도록 하겠습니다.

나. 비례율 산정의 하자로 관리처분계획이 무효로 판단될 수 있는지 여부

(1) 관련 법리

대법원 2002. 12. 10. 선고 2001 두 6333 판결은 “관리처분계획에 하자가 있어 그것이 무효로 되기 위해서는 그 하자가 중대하고도 명백할 것이 요구된다고 할 것인바, 비례율의 부당적용과 같이 관리처분계획에서 정한 청산금의 산정방법에 하자가 있는 경우라도 그러한 하자는 다른 특별한 사정이 없는 한 중대하고도 명백하다고 볼 수 없어 이러한 하자를 사유로 하여 관리처분계획을 무효로 볼 수는 없다.”고 판시하였습니다.

아울러 대법원 2008. 2. 14. 선고 2006 다 33470, 2006 다 33487 판결은 “행정처분에 하자가 있어 그 처분이 무효로 되기 위해서는 그 하자가 중대하고도 명백할 것이 요구되는바, 재개발조합의 청산금부과처분에 법령 위반의 하자가 있는 경우라도 부과대상이 아니거나 납부의무 없는 자에 대한 부과처분과 같이 부과처분을 하지 않았어야 함에도 잘못 부과처분을 한 경우에는 그 하자가 중대하고도 명백하다고 할 수 있을 것이나, 단순히 청산금 산정

² 관리처분계획 취소소송은 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내, 또는 처분이 있는 날부터 1년 이내에 제기해야 하는데(행정소송법 제20조), 귀 조합은 2018년경에 최초 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았으므로, 이미 제소기한이 도과되어 조합원 등이 관리처분계획에 대한 취소소송을 제기할 수 없습니다.

방법이 잘못된 경우에는 그 하자가 중대하고도 명백하다고 할 수 없다”고 판시한 바 있습니다.

비록 위 각 대법원 판결은 해당 원고들이 청산금 산정에 대하여 다툼 사안에 관한 것이나, 위와 같은 법리에 따라 비례율 적용의 하자로 인하여 관리처분 계획이 무효에 해당하는지 여부는 엄격하게 판단될 가능성이 높고, 특히 이 사건 관리처분계획에 존재하는 비례율 계산의 오류는 청산금 산정과 가장 밀접한 관련이 있다는 점에서 그 하자가 중대·명백한지 여부가 엄격하게 판단될 가능성이 높습니다.

이와 관련하여, 서울행정법원 2018. 8. 31. 선고 2017 구합 74306 판결은 「상가 조합원 비례율 산정이 자의적으로 산정되어 형평에 반하는 것으로 판단된 사안」에서, “관리처분계획은 조합원에게 구체적이고 결정적인 영향을 미치는 것이고, 특히 이 사건 **관리처분계획에 포함된 비례율은 추후 이 사건 상가 조합원의 부담금을 결정하는 토대가 되는 것으로서 그에 존재하는 위법사유는 중대성이 인정된다**.” 다만 이 사건 관리처분계획에 존재하는 하자는 **비례율 산정방식이 자의적이고 형평에 반한다는 것으로서** 계획의 수립 및 인가·고시 당시에는 그러한 사정이 쉽게 드러나 있지 않았고, 이 사건 관리처분계획에는 ‘상기 비례율은 추정치로써 조합과 상가 조합원이 별도로 정하는 약정에 따라 수립되는 관리처분계획으로 변동될 수 있다’고 명시되어 있었던 점 등에 비추어 볼 때 이러한 하자는 객관적으로 명백한 것이라고 할 수 없다.”고 판단한 바 있습니다.

(2) 이 사건의 경우 – 비례율 산정의 하자가 중대·명백한 하자인지 여부

이 사건의 경우, 비례율 산식의 분모에 오류가 있는 것일 뿐, 특정 조합원의 종전자산 평가액을 잘못 산정하는 등으로 조합원 간 형평에 반하는 것으로 보기 어렵고, 위 서울행정법원 2018.8.31. 선고 2017 구합 74306 판결 사안과 같이 **조합원의 권리·의무에 중대한 영향을 미친다고 단정할 수 없을 것으로 보인다**.

특히 비례율 산정의 오류로 인하여 조합원이 향후 부담할 분담금 내지 청산금에 차이가 발생한다고 하더라도, 귀 조합의 수입과 비용이 변경된 것은 아니므로, 중국적으로는 분담금 내지 청산금이 조합원 내부적으로 조정되어 비례

을 산정의 오류가 조합원에게 영향을 미칠 가능성이 크지 아니할 것으로 보입니다(즉 비례율은 조합의 수입과 비용을 토대로 산정되는 것으로서, 그 산식에 일부 오류가 있다고 하더라도 조합의 수입과 비용에 직접 영향을 미치지 아니하고, 개별 조합원의 분담금이나 환급금에도 별다른 영향을 미치지 않는 것입니다).

이에 더하여, 비례율 변경이 조합원의 종전자산 평가액에 따라 분담금 내지 청산금에 미치는 영향이 일부 상이하게 된다고 가정하더라도, 대법원은 정비사업조합에게 관리처분계획 수립에 관한 광범위한 재량이 인정된다고 판단한 바 있으므로, 비례율 산정이 잘못된 것은 특정 조합원의 재산권을 본질적으로 침해하지 아니하다고 보기는 어렵습니다.

즉 대법원 2010. 10. 28. 선고 2009 두 4029 판결은 “적법하게 인가된 관리처분계획이 종전의 토지 또는 건축물의 면적·이용상황·환경 그 밖의 사항을 종합적으로 고려하여 대지 또는 건축물이 균형 있게 분양신청자에게 배분되고 합리적으로 이용되도록 하는 것인 이상, 그로 인하여 토지등소유자들 사이에 다소 불균형이 초래된다고 하더라도 그것이 **특정 토지등소유자의 재산권을 본질적으로 침해하는 것이 아닌 한, 이에 따른 손익관계는 종전 자산과 중후자산의 적절한 평가 등을 통하여 청산금을 가감함으로써 조정될 것이므로, 그러한 사정만으로 그 관리처분계획을 위법하다고 볼 수는 없다.**”고 판시한바, 비례율 산정의 오류는 중대한 하자에 해당하지 아니하는 것으로 판단될 가능성이 상당히 있습니다.

한편, 서울고등법원 2019. 2. 14. 선고 2018 누 55427 판결은 “비례율 산정의 기준이 되는 '종전의 토지 및 건축물의 총 가액'에는 현금청산자를 제외한 조합원 소유의 종전 토지 및 건축물의 가액만이 포함된다고 보아야 한다.”고 판단한 바 있고, 앞서 설명드린 바와 같이 분양신청을 하지 아니한 종교시설 소유자는 현금청산대상자에 해당한다는 점에 관한 법리가 확립되어 비례율 산정의 하자가 명백하다고 판단될 가능성을 완전히 배제하기는 어렵습니다.

그러나 귀 조합의 관리처분계획상 귀 조합이 현금청산대상자인 이 사건 각 종교재단이 소유한 종교시설의 종전자산평가액을 분모에 포함하여 비례율을 산정하였다는 사정이 쉽게 드러나 있지 아니하고, 귀 조합이 관리처분계획을 수립할 당시에는 대통합의에 관한 법리가 명확하게 정립되지 아니하여 그 하자

가 명백하지 아니하였다고 볼 여지도 있으므로, 비례율 산정에 관한 하자가 객관적으로 명백하지는 아니하였던 것으로 판단될 수 있을 것으로 보입니다.

(3) 소결론 - 관리처분계획의 유효 여부

위와 같은 사정들을 종합해 볼 때, 귀 조합이 수립한 관리처분계획의 비례율에 일부 하자가 인정된다고 하더라도, 이를 중대하고도 명백한 하자로 보기는 어려우므로, 위 관리처분계획이 무효로 판단되어 효력이 상실된다고 단정하기는 어려운 것으로 판단됩니다(위와 같은 중대성 내지 명백성이나 이에 따른 관리처분계획의 무효 여부는 해당 소송이 제기되면 최종적으로 법원에서 판단할 부분이어서, 단정적인 의견을 드리기 쉽지 아니한 측면이 있습니다만, 현재까지의 사정들만 놓고 보았을 때 관리처분계획이 무효라고 판단될 가능성은 높지 아니할 것으로 보입니다).

(4) 보론 - 비례율 산정의 하자가 중대·명백한 하자로 판단될 경우

앞서 설명드린 바와 같이, 관리처분계획상 비례율 산정의 하자는 중대·명백하지 아니한 것으로 판단될 가능성이 높으나, 만일 관리처분계획이 당연무효인 것으로 판단될 경우 아래와 같은 리스크가 발생할 수 있습니다.

관리처분계획 무효확인소송이 제기되어 관리처분계획 무효를 확인하는 판결이 선고되어 확정되거나, 그 이전에라도 관리처분계획의 효력정지가 이루어질 경우, 관리처분계획이 유효함을 전제로 이루어질 수 있는 이전고시, 조합 해산 등의 절차는 더 이상 진행될 수 없게 됩니다.

따라서 비례율 산정에 관한 하자로 인하여 관리처분계획이 무효인 것으로 판단되는 경우, 귀 조합은 이 사건 각 종교재단의 종전자산평가액을 분모에서 제외하여 비례율을 다시 산정하고, 이를 기초로 관리처분계획을 다시 수립하여야 할 것입니다.

만일, 관리처분계획이 당연무효인 것으로 판단될 경우, 기존 관리처분계획에 기반한 행정행위가 효력을 상실하게 될 우려가 있는데, 수용재결을 비롯한 후속 행정행위들의 경우 이미 취소소송의 제소기간이 대부분 경과하였을 것으로 보이고, 무효소송이 제기되더라도 중대·명백한 하자가 아니라는 논리를 토대로 하여 어느 정도 방어가 가능할 수 있을 것으로 보입니다.

다. 관리처분계획의 하자 치유 절차와 이전고시 전 완료 필요 여부

(1) 관리처분계획 변경 절차

관리처분계획 중 비례율에 관한 하자를 치유하기 위해서는 관리처분변경 계획에 관한 조합원 총회 결의를 하고, 변경된 관리처분계획에 관한 관리처분계획 변경인가를 득하여야 합니다.

구체적으로, 도시정비법 제 74 조 제 1 항은 “사업시행자는 제 72 조에 따른 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 다음 각 호의 사항이 포함된 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등의 인가를 받아야 하며, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.”고 규정하여 경미한 사항을 변경하는 경우가 아닌 한 관리처분계획에 관한 시장·군수등의 인가를 득하도록 규정하고 있습니다.

관리처분계획의 경미한 변경에 관한 도시정비법 시행령 제 61 조 제 1 호는 “계산착오·오기·누락 등에 따른 조서의 단순정정인 경우(불이익을 받는 자가 없는 경우에만 해당한다)”라고 규정하고 있는데, 비례율의 변경은 조합원의 부담금 및 청산금에 영향을 미치는 것으로서 단순정정이라고 보기 어렵고, 현금청산대상자의 종전자산평가액을 포함한 것은 법률(도시정비법) 적용의 착오에 해당하는 것으로서 ‘계산착오’에 해당한다고 보기 어려우므로, 종전자산평가액을 수정하여 비례율을 정정하는 것은 경미한 사항의 변경에 해당하지 아니할 것으로 보입니다.

특히 귀 조합의 설명에 의하면, 이 사건 각 종교재단의 종전자산 평가액을 비례율 산정에 있어 분모에서 제외할 경우 비례율이 기존 125%에서 약 140%로 증가할 것으로 예상된다는 것인바, 비례율이 15% 상당 변경되는 것이 경미한 변경에 해당한다고 보기는 어려울 것으로 사료됩니다.

따라서 귀 조합이 비례율을 수정하기 위해서는 수정된 관리처분계획에 관한 총회 결의를 거쳐, 관할 행정청으로부터 변경된 관리처분계획에 관한 인가를 득하여야 할 것으로 사료됩니다.

(2) 관리처분계획 변경 필요 여부

관리처분계획에 하자가 존재함이 확인되는 경우, 조합원은 관리처분계획의 하자가 존재함을 이유로 그에 관한 분쟁이 발생할 가능성이 있고, 만에 하나 관리처분계획의 효력이 부정될 경우 재차 관리처분계획을 수립하여야 하며, 해당 기간 동안 귀 조합의 귀책사유로 인하여 사업 진행이 지연될 수 있으므로, 관리처분계획을 변경하는 것이 보다 안전한 방안이 될 것으로 사료됩니다.

또한, 귀 조합이 관리처분계획 변경을 위한 총회 결의를 득하고, 그에 관한 관리처분계획변경인가를 득하게 되면 비례율 산정의 오류로 인한 리스크를 최소화할 수 있게 될 것으로 보입니다.

즉, 대법원 2016. 6. 23. 선고 2014 다 16500 판결은 “당초 관리처분계획의 경미한 사항을 변경하는 경우와는 달리 당초 관리처분계획의 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용으로 새로운 관리처분계획을 수립하여 시장·군수의 인가를 받은 경우에는 당초 관리처분계획은 달리 특별한 사정이 없는 한 효력을 상실한다.”고 판시한 바 있습니다.

앞서 살펴본 바와 같이, 비례율을 변경하는 것은 도시정비법 시행령 제 61 조의 경미한 사항 변경에 해당하지 아니할 것으로 보이므로, 관리처분계획 중 비례율에 관한 부분이 변경되고, 그에 관한 인가를 득할 경우에는 더 이상 기존 관리처분계획의 하자에 관하여 다룰 수 없게 되므로, 비례율의 하자에 따른 사업 지연 가능성을 차단할 수 있게 될 것으로 보입니다.

(3) 이전고시 이전에 관리처분계획을 변경하여야 하는지 여부

관리처분계획 변경 시점과 관련하여, 대법원 2012.4.13. 선고 2009두 9635 판결은 “도시 및 주거환경정비법에 따른 이전고시의 효력 발생으로 이미 토지 등소유자 등에 대하여 획일적·일률적으로 처리된 권리귀속 관계를 모두 무효화시키고 다시 처음부터 관리처분계획을 수립하여 이전고시 절차를 거치도록 하는 것은 정비사업의 공익적·단체법적 성격에 배치된다고 할 것이므로, 이전고시가 그 효력을 발생하게 된 이후에는 토지등소유자 등이 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 타당하다”고 판시한 바 있으므로, 이 사건 사업에 관한 이전고시가 이루어질 경우에는 관리처분계획의 효력에 관하여 다룰 소의 이익이 존재하지 아니하게 됩니다.

따라서 이른 시일 내에 이전고시가 이루어진다면 관리처분계획의 하자가 문제 될 수 없겠으나, 이 사건 사업 전체의 준공이 2026. 12.에 예정되어 있고, 이전 고시는 그 이후에 진행될 예정이라는 귀 조합의 설명에 의하면 이 사건 사업의 이전고시가 이루어지기까지는 적어도 4 개월 이상이 필요할 것으로 보이므로, 해당 시점 이전에 관리처분계획을 변경하는 것이 보다 안전한 방안이 될 것으로 판단됩니다.

라. 소결론

이상에서 본 바와 같이, 비례율 산정 시 포함되는 종전자산평가액에는 분양대상자의 종전자산평가액만 포함되어야 하므로, 현금청산대상자인 종교재단의 종전자산평가액이 포함되어 비례율이 산정된 것은 관리처분계획의 하자를 구성하게 될 수 있으나, 이러한 하자가 중대·명백하다고 볼 수 없는 이상, 현재의 관리처분계획이 무효로 판단될 가능성은 높지 아니할 것으로 판단됩니다.

한편, 비례율의 변경은 관리처분계획의 경미한 변경에 해당하지 아니하므로, 귀 조합이 관리처분계획 중 비례율에 관한 하자를 치유하기 위해서는 관리처분변경 계획에 관한 조합원 총회 결의를 받고, 변경된 관리처분계획에 관한 관리처분계획변경인가를 득하여야 할 것으로 보이며, 추가적인 사업 지연 및 분쟁을 미연에 방지하기 위해서는 이전고시 이전에 관리처분계획 변경 절차를 거치는 것이 보다 안전할 것으로 사료됩니다.

3. 질의 3.에 관하여 – 조합장 선임의 적법성 및 하자 치유방안 검토

가. 문제의 소재

앞서 1.의 나.항에서 검토한 바와 같이 이 사건 각 종교재단은 현금청산대상자에 해당하는데, 귀 조합 정관 제 11 조 제 2 항은 “제 44 조 제 1 항의 분양신청 기한 내에 분양신청을 하지 아니한 자는 조합원 자격이 상실된다.”고 정하고 있으므로, 이 사건 각 종교재단이 현금청산대상자로 되어 조합원의 지위를 상실한 시점은 귀 조합의 분양신청 기간(최초 2017. 2. 1. ~ 2017. 3. 7. 연장 2017. 3. 8. ~ 2017. 3. 20.) 종료 후인 2017. 3. 21.경이 될 것으로 보입니다.

그런데, 기독교대한감리회유지재단의 대리인이 귀 조합의 조합장으로 당선된 시점(2024. 12. 2.)은 기독교대한감리회유지재단이 조합원의 지위를 상실한 시점

으로부터 이미 상당 기간이 경과한 후이므로, 조합원 자격을 상실한 법인의 대리인이 귀 조합의 조합장으로 선임될 수 있는지, 나아가 그러한 자를 조합장으로 선임한 총회 결의가 적법한지 여부가 문제됩니다.

아울러 귀 조합의 조합장 선임이 부적법한 것으로 판단될 경우, 그와 같이 적법한 대표권을 갖추지 못한 조합장 재직 기간 동안 이루어진 총회 결의나 각종 계약의 체결 및 그 밖의 조합 업무에 관한 법률행위 등의 효력에도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

이에 이하에서는 기독교대한감리회유지재단의 대리인이 귀 조합의 조합장으로 선임된 것이 적법한지 여부와 함께, 위 조합장 선임 이후 이루어진 총회 결의 및 계약 등 후속 법률행위의 효력이 유효하게 존속하는지 여부를 검토하고, 만일 기존 결의나 계약의 효력이 부인될 경우 귀 조합의 사업의 연속성과 안정성을 확보하기 위하여 기존 결의나 계약의 효력을 유지시킬 수 있는 하자치유 방안에 대하여 살펴보겠습니다.

나. 현금청산대상자인 기독교대한감리회유지재단의 대리인을 조합장으로 선임한 것이 적법한지 여부

(1) 현금청산대상자인 법인의 대리인에게 조합장 피선임 자격이 있는지 여부

도시정비법 제41조 제1항은 조합 임원에 관하여 “조합은 조합원으로서 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지(재건축사업의 경우에는 건축물과 그 부속 토지를 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 소유한 자[하나의 건축물 또는 토지의 소유권을 다른 사람과 공유한 경우에는 가장 많은 지분을 소유(2인 이상의 공유자가 가장 많은 지분을 소유한 경우를 포함한다)한 경우로 한정한다] 중 다음 각 호의 어느 하나의 요건을 갖춘 조합장 1명과 이사, 감사를 임원으로 둔다.”고 정하고 있는바, 조합장으로 선임되기 위하여는 조합원으로서 정비구역 내의 건축물 또는 토지를 소유하고 있어야만 합니다³.

³ 참고로 귀 조합 정관 제15조 제2항은 조합 임원의 자격에 관하여 ‘조합원’일 것을 명시하고 있지는 아니하나, “정비구역에서 거주(영업하는 자의 경우 영업을 말한다)하는 자로서 선임일 직전 3년 동안 정비구역 내 거주 기간이 1년 이상일 것(제15조 제2항 제1호)” 또는 “정비구역에 있는 건축물 또는 토지를 5년 이상 소유하고 있을 것(제15조 제2항 제2호)”에 해당하는 자를 임원으로 선임하여야 한다고

한편, 도시정비법 제45조 제5항 제3호는 조합원이 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있는 사유로 “법인인 토지등소유자가 대리인을 지정하는 경우”를 정하면서, “이 경우 법인의 대리인은 조합임원 또는 대의원으로 선임될 수 있다.”고도 명시하고 있습니다. 즉, 위 규정에 따르면 조합원인 법인의 대리인은 조합임원으로 선임될 수 있다고 할 것입니다.

요컨대, 법인의 대리인도 조합장으로 선임될 수 있는 것이지만, 이는 어디까지나 해당 법인이 **조합원으로서** 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지를 소유한 자이면서 도시정비법 제41조 제1항 각 호의 어느 하나의 요건을 갖춘 자인 때에 한하여 그 자격이 인정된다고 봄이 상당합니다.

따라서 현금청산대상자로서 조합원 지위를 상실한 기독교대한감리회유지재단의 대리인은 조합장으로 선임될 수 있는 자격을 갖추지 못한 것으로 판단됩니다.

(2) 무자격자를 조합장으로 선임한 총회결의의 효력

조합 임원으로서의 자격을 갖추지 못한 자를 조합장으로 선임한 결의의 효력에 관하여, 다수의 하급심 판례들은 애당초 도시정비법령 내지 정관 규정에서 정한 조합 임원으로서의 자격 요건을 충족하지 못하여 조합 임원 피선임권이 없는 자를 조합장으로 선출한 결의에는 중대한 하자가 있으므로 무효라고 판단하고 있습니다(광주지방법원 2021. 1. 15. 선고 2020 가합 57061 판결, 부산지방법원 동부지원 2018. 5. 9. 선고 2017 가합 104537 판결, 수원지방법원 안산지원 2016.5.26. 선고 2015 가합 22738 판결 등 참조).

특히, 광주지방법원 2021.1.15. 선고 2020가합57061 판결은 “C은 이 사건 결의 당시 도시정비법 제41조 제1항 제2호가 정한 조합 임원 자격요건인 '정비구역에 위치한 건축물과 그 부속 토지를 5년 이상 소유하고 있을 것'을 충족하지 못하여 조합 임원 자격이 없고, 달리 C이 조합 임원 자격요건을 충족하였음을 인정할 증거가 없다. 따라서 조합 임원 자격이 없는 C을 피고 조합장으로 선임한 이 사건 결의에는 도시정비법 제41조 제1항을 위반한 중대한 하자가 있어 이를 무효라고 봄이 타당하다.”고 판시하며, 도시정비법

정하고 있습니다.

제41조 제1항에서 정한 조합 임원의 자격 요건을 결한 자를 조합장으로 선임한 결의에는 결의를 무효로 할 만한 중대한 하자가 있다고 판단하였습니다.

이 사건에서도 특별한 사정이 없는 한 현금청산대상자인 기독교대한감리회유지재단의 대리인을 귀 조합의 조합장으로 선임한 총회 결의 역시 조합 임원의 자격이 없는 자를 조합장으로 선임한 것으로서 도시정비법 제41조 제1항을 위반한 중대한 하자가 있어 무효로 판단될 것입니다.

다. 조합장 선임이 무효인 경우에도 조합장이 선임 이후에 한 행위의 효력이 유지되는지 여부

(1) 조합장 선임이 무효인 경우, 무자격자에 의하여 소집된 총회 결의의 효력 및 체결된 계약의 효력

(가) 무효인 조합장 선임 결의에 의하여 선출된 조합장이 개최한 후속 총회는 적법한 소집권한이 없는 자에 의하여 소집된 총회이므로 무효라고 보는 것이 법원의 일관된 입장입니다(대법원 2014. 10. 27. 선고 2011 다 37360 판결, 부산고등법원 2018. 5. 24. 선고 2017 나 53449 판결, 서울서부지방법원 2023. 5. 25. 선고 2022 가합 36653 판결 등 참조).

한편, 무효인 임원 선임 결의가 있는 후라도 그 후에 다시 개최된 총회에서 위 종전 선임 결의를 그대로 재인준하거나 다시 같은 내용의 결의를 하는 경우에는 그 후속 총회는 당초의 임원 선임 결의에 의하여 선임된 임원에 의하여 소집된 총회라 하더라도 이를 독립된 무효 사유로 볼 수는 없다는 법리가 존재하기는 하나(대법원 2003. 9. 26. 선고 2001 다 64479 판결), 이는 그 후속 총회의 취지상 소집권자의 무권한을 무효사유로 본다면 최초의 임원선임결의의 무효로 연쇄적으로 그 후의 결의가 모두 무효로 되는 결과가 되어 법률관계의 혼란을 초래하고 법적 안정성을 현저히 해하게 된다는 측면에서 인정되는 법리이므로, 후속 총회가 당초 무효인 임원 선임 결의를 재인준하거나 같은 내용의 결의를 하는 경우가 아닌 이상 적용되기 어렵습니다.

실제로 법원은 무효인 조합장 선임 결의 이후 해당 조합장이 개최한 후속 총회의 결의 사항이 조합의 사업추진과 관련된 내용 또는 조합정관이나 규정 등을 변경하는 것이라면 그 후속 총회는 적법한 소집권자에 의하여 소집된 총회

에서 결의되지 아니하였으므로 무효라고 판단하고 있습니다(부산고등법원 2011. 4. 12. 선고 2010나8884 판결, 인천지방법원 2025. 1. 22.자 2024카합10283 결정 등 다수 참조).

(나) 그러나 아래에서 살펴보는 바와 같이, 본건의 경우에는 도시정비법 제43조 제2항, 조합 정관 제17조 제2항이 적용될 수 있을 것이므로, 귀 조합의 조합장이 당연 퇴임하면서도 퇴임 전에 관여한 이사회, 대의원회, 총회 결의 등은 유효성이 인정될 수 있고, 조합장 지위에서 체결한 계약을 비롯한 각종 법률행위도 유효한 것으로 인정될 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.

다만, 분쟁의 소지를 없애기 위해서는 후술하는 바와 같이 **적법한 직무대행자 내지 새로운 조합장을 선임하고 새로 총회를 개최하여 기존 조합장의 각종 법률행위 등을 추인하는 결의를 할 필요성이 있을 것이고,** 이러한 경우 적법하게 정비사업을 계속 시행할 수 있을 것으로 사료됩니다.

(2) 도시정비법 제43조 제3항 및 귀 조합 정관 제17조 제3항에 따라 당연 퇴임 조합장의 퇴임 전 관여 행위로서 그 효력이 유지될 가능성이 있는지 여부

(가) 문제의 소재

위 다의 (1)항에서 살펴본 바와 같이, 무효인 조합장 선임 결의에 기하여 선임된 조합장이 소집·개최한 총회 결의 및 계약 체결 행위 등은 무효로 되는 것이 원칙이나, 도시정비법과 귀 조합 정관상 자격 요건을 갖추지 못하여 당연 퇴임되는 조합 임원이 퇴임 전 관여한 행위는 효력을 잃지 아니한다는 취지의 규정이 존재하는바(도시정비법 제43조 제3항 및 귀 조합 정관 제17조 제3항), 이하에서는 위 규정들에 기하여 조합장 선임이 무효라 하더라도 기존의 총회 결의나 계약 체결의 효력이 유지될 수 있는지 여부에 관하여 검토합니다.

(나) 관련 규정 및 판례 법리

귀 조합 정관 제17조 제2항은 “임원이 제1항 각호의 1에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 판명되거나 선임 당시에 제15

조 제2항⁴에 해당하지 않는 것으로 판명된 경우 당연히 퇴임한다.”고 정하면서, 동조 제3항에서 “제2항의 규정에 따라 퇴직시킨 임원이 퇴직 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.”고 정하고 있습니다.

한편, 도시정비법 제43조 제3항도 귀 조합 정관 제17조 제3항과 동일하게 “제2항에 따라 퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.”고 정하고 있고, 관련 규정들은 아래와 같습니다.

도시 및 주거환경정비법 제43조(조합임원 등의 결격사유 및 해임) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 조합임원 또는 전문조합관리인이 될 수 없다.

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
5. 이 법을 위반하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 10년이 지나지 아니한 자
6. 제35조에 따른 조합설립 인가권자에 해당하는 지방자치단체의 장, 지방의회의원 또는 그 배우자·직계존속·직계비속

② 조합임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연 퇴임한다.

1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 밝혀진 경우
2. 조합임원이 제41조 제1항에 따른 자격요건을 갖추지 못한 경우

③ 제2항에 따라 퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

제41조(조합의 임원) ① 조합은 조합원으로서 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지(재건축사업의 경우에는 건축물과 그 부속토지를 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 소유한 자 [하나의 건축물 또는 토지의 소유권을 다른 사람과 공유한 경우에는 가장 많은 지분을 소유(2인 이상의 공유자가 가장 많은 지분을 소유한 경우를 포함한다)한 경우로 한정한다]

⁴ 권선113-6구역 조합 정관 제15조(임원) ② 조합 임원은 조합원 과반수 출석과 서면결의서를 포함한 투표자 중 조합장은 최다득표자를, 감사와 이사는 입후보자 중 다득표순으로 다음 각호의 1에 해당하는 자 중 총회에서 선임한다. 이 경우 조합장은 선임일로부터 법 제74조 제1항에 따른 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에 거주하여야 하고 임기 중 공석이 된 경우에는 조합원 중에서 대의원회가 이를 보궐선임한다.)

1. 정비구역에서 거주(영업하는 자의 경우 영업을 말한다)하는 자로서 선임일 직전 3년 동안 정비구역 내 거주 기간이 1년 이상일 것
2. 정비구역에 있는 건축물 또는 토지를 5년 이상 소유하고 있을 것

다] 중 다음 각 호의 어느 하나의 요건을 갖춘 조합장 1명과 이사, 감사를 임원으로 둔다. 이 경우 조합장은 선임일부터 제74조 제1항에 따른 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에서 거주(영업을 하는 자의 경우 영업을 말한다. 이하 이 조 및 제43조에서 같다)하여야 한다.

1. 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지를 5년 이상 소유할 것
2. 정비구역에서 거주하고 있는 자로서 선임일 직전 3년 동안 정비구역에서 1년 이상 거주할 것

위 제43조 제2항 제1호는 “제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 지이었음이 밝혀진 경우”라고 정하고 있는 반면, 제2항 제2호는 “조합임원이 제41조 제1항에 따른 자격요건을 갖추지 못한 경우”라고만 정하고 있는바, 조합 임원으로 선임된 이후에 사후적으로 조합원 지위를 상실하게 되는 경우에는 제43조 제2항 제2호가 적용될 이 명백합니다만, 임원 선임 당시부터 조합원 지위가 없어 임원으로 선임될 자격이 애초부터 없는 경우에도 제43조 제2항 제2호가 적용될 수 있는지에 관해서는 의문이 있을 수 있습니다(즉 제1호에서는 ‘선임 당시 그에 해당하는 지이었음이 밝혀지는 경우’라고 명확하게 규정하고 있으나, 제2호에서는 이러한 내용이 존재하지 않아, 견해의 대립이 있을 수 있는 것입니다).

살피건대, i) 다수의 하급심 판례들은 선임 당시부터 자격요건을 갖추지 못한 채 조합장으로 선임된 경우에도 도시정비법 제43조 제2항 제2호에 의하여 조합장이 당연 퇴임하는 것으로 판단하고 있는 점{부산고등법원 2021. 10. 28. 선고(창원) 2021나12318 판결, 서울중앙지방법원 2022. 1. 13. 선고 2020가합607612 판결(확정) 등 참조}, ii) 도시정비법 제43조 제3항의 규정 취지는 선임 당시부터 결격사유가 있는 자가 임원으로 선임된 경우에도 법적 안정성을 고려하여 그 임원이 관여한 행위가 효력을 잃지 않도록 하기 위한 것이라는 점 등을 고려하였을 때, 귀 조합 정관 제17조 제2항이나 도시정비법 제43조 제2항 제2호의 당연 퇴임 규정은 선임 당시부터 조합원 지위 등의 자격요건을 갖추지 못한 자가 임원으로 선정된 경우에도 적용되어야 할 것으로 판단됩니다.

요컨대, 선임 당시부터 현금청산대상자로서 조합원으로서의 자격을 상실한 자가 조합 임원으로 선임된 경우에는 당연 퇴임 사유가 존재한다고 판단될 가능성이 높고, 이 경우 해당 조합임원이 한 행위의 효력이 유효하게 존속된다고 평가될 것입니다.

(3) 소결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 귀 조합의 조합장은 무자격자로서 임원으로 선정될 수 없었으므로, 조합장 선출 결의는 무효로 판단되고, 다만 도시정비법 제43조 제2항, 제3항, 조합 정관 제17조 제2항, 제3항에 따라 조합장은 당연 퇴임 하되, 퇴임 전에 관여한 각종 법률행위의 효력은 유효한 것으로 판단될 수 있을 것입니다.

다만, 이 부분 쟁점에 관한 명시적인 대법원 판례가 없어 위와 같은 해석에 이견이 제시될 수 있고, 일부 조합원 등이 소송 등을 제기할 경우 불필요한 논란이 발생할 여지도 있으므로, 아래에서 살펴보는 것처럼 총회 결의를 통해 기존 결의 및 각종 계약에 관한 추인 결의를 해 둘 필요성이 상당히 있을 것으로 사료됩니다.

라. '기존 총회 결의 및 체결된 계약'의 하자 치유 방안

(1) 총회 결의를 통한 추인의 가능성 및 절차상 유의점

먼저 기존 결의 및 계약의 효력을 유지하기 위하여 귀 조합으로서는 조합원들의 최고 의사결정기관인 총회 결의를 통한 추인 방안을 고려하여 볼 수 있을 것입니다.

무권대리행위나 무효행위의 추인은 무권대리행위 등이 있음을 알고 그 행위의 효과를 자기에게 귀속시키도록 하는 단독행위로서 그 의사표시의 방법에 관하여 일정한 방식이 요구되지 않는다고 봄이 대법원의 입장이나(대법원 2017. 10. 26. 선고 2016 다 247223 판결 참조), 위 판례 법리를 고려하였을 때, 조합원들이 스스로 어떤 행위를 추인하는지 구체적으로 알고 자유롭게 안전에 대한 찬성 또는 반대의 의사를 결정할 수 있어야만 조합원의 의결권을 침해하지 아니하는 적법한 추인 결의로 될 것으로 사료됩니다.

다만, 추인 결의를 위한 안건 상정 시, 도시정비법령이나 귀 조합 정관상 총회의 상정할 수 개의 안건을 하나의 안건으로 묶어 일괄 상정하는 것을 금지하고 있지 아니하고, 달리 안건 상정에 관한 방식 등에 관하여 아무런 제한을 가하고 있지도 아니하므로 수 개의 총회 결의 또는 수 개의 계약 체결 건에 관한 추인의 안건을 일괄하여 상정하는 것도 가능할 것입니다. 그러나 무효행위의 추인이 인정되기 위하여는 조합원들이 추인 대상 행위가 무효임을 인식하면서도 그 법률 효과를 조합에 귀속시키려는 의사가 인정되어야 하므로, ‘선임 결의가 무효로 된 조합장의 기존 업무 일체 추인의 건’과 같이 추인 대상을 포괄적·추상적으로 표시하여 안건을 상정하는 경우에는 추인의 효력이 부인될 위험이 있다고 사료됩니다.

이에 추인의 대상이 되는 행위들을 구체적으로 특정하여 총회 책자에도 추인하려는 총회 결의의 일시, 안건, 주요 내용 등 그 세부 사항과 추인하려는 계약의 체결 사실, 상대방 및 그 구체적인 의무·부담 내용 등을 조합원들이 명확하게 인지할 수 있도록 한 상태에서 추인 결의를 진행함이 안전할 것으로 보입니다.

구체적으로, ① 수원고등법원 2022. 5. 20. 선고 2021 나 16474 판결은 「각 용역계약에 대한 추인의 건을 하나의 안건으로 일괄 상정한 사안」에서 “조합원들에게 이 사건 각 용역계약 별로 용역업체, 용역내용, 계약금액 등이 기재되어 있는 각 정기총회 안내책자를 배포하였는바, 위 각 안내책자에는 위 각 정기총회의 의안이 무엇인지 알기에 족한 정도로 구체적으로 기재되어 있어 위 각 정기총회 당시 조합원들의 자유로운 의사결정에 어떠한 제한이 있었다고 보기 어렵다.”고 판시하였고, ② 서울중앙지방법원 2023. 2. 2. 선고 2021 가합 560420 판결은 「선임이 무효로 된 조합임원에 의하여 체결된 다수의 소송위임계약을 하나의 안건으로 일괄 상정하여 추인 결의를 한 사안」에서 “위 임시총회 책자에는 제 4 호 안건과 관련하여 53 건에 달하는 이 사건 각 위임계약의 체결일자, 사건명, 선임료 등 채권의 금액이 구체적으로 명시된 목록이 첨부되어 있는 사실이 인정된다”며 일괄 추인을 유효한 것으로 판단하였는바, 위와 같이 추인하려는 사항에 관한 세부 정보를 조합원들에게 상세히 제공함이 바람직할 것으로 사료됩니다.

(다) 아울러, 적법한 소집권자에 의하여 추인 총회가 소집되어야만 향후 추가

적인 분쟁의 소지를 방지할 수 있을 것입니다. 귀 조합의 설명에 따르면 현재 까지 기독교대한감리회유지재단의 대리인이 귀 조합의 조합장직을 수행하고 있다는 것인데, 현 상황에서 위 조합장이 주인을 위한 총회를 소집한다면 위 총회가 개최되어 주인 결의가 이루어진다 하더라도 적법한 결의로 평가되기 어렵습니다.

따라서 귀 조합으로서는 조합장 유고 등의 경우 직무대행자 순위를 정한 조합 정관 제 16 조 제 6 항⁵에 따라 직무대행체계를 확립하여 적법한 직무대행자로 하여금 주인 결의를 위한 총회를 소집하도록 하거나⁶, 주인 결의를 진행하기에 앞서 새로운 조합장 선임 결의를 거친 후 새로운 조합장이 주인 결의를 위한 총회를 소집·개최하여야 할 것으로 사료됩니다.

현실적인 방안으로, 귀 조합은 ① 위 정관 제 16 조 제 6 항에 따라 상근이사 또는 이사 중 최연장자가 이사회를 소집하여 조합장 직무대행자를 선정하고(이 때 기존 조합장은 당연 퇴임한 상황이므로 이사회에 참석할 수 없고, 직무대행자는 가급적 이사들 중에서 선임하는 것이 안전할 것입니다), ② 해당 직무대행자가 새로운 조합장 선임을 위한 조합원 총회를 소집하여 해당 총회에서 조합장을 선출하며, ③ 신규 조합장이 관리처분계획 변경을 비롯한 후속 사업을 진행하는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다.

(2) 이전고시 전후의 시점 별 유의사항

우선, 이전고시 전후 여부와 관계없이 귀 조합으로서는 적법한 직무대행 체계를 확립하거나 적법한 조합장을 새로이 선임한 이후에 이전고시 절차를 진행

5 귀 조합 정관 제16조(임원의 직무 등) ⑥ 조합장이 유고 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 선출된 자가 그 직무를 대행한다. 이 경우 이사회 소집은 상근이사 또는 이사 중 최연장자가 할 수 있으며, 최연장자가 회의 소집 포기를 서면으로 한때에는 그다음 순위 연장자가 직권으로 소집할 수 있다.

6 법원은 정비사업에서 조합장 ‘유고’의 의미에 관하여 비교적 폭넓게 판단하고 있습니다. 원칙적으로 ‘유고 등’은 “조합장의 임기가 만료되기 전 조합장이 사망, 질병 등 기타 부득이한 사정으로 그 직무를 집행할 수 없는 경우”를 의미하나(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010다3384 판결 참조), 법원은 벌금형을 선고받아 조합장 지위를 상실하게 된 경우(부산고등법원 2018. 5. 24. 선고 2017나53449 판결), 조합장의 직무집행이 정지된 경우(서울중앙지방법원 2021. 6. 23. 선고 2020가합4367 판결), 조합장이 자의로 사임하거나 해임되어 그 직무를 수행할 수 없는 경우(서울고등법원 (인천)2025. 7. 3. 선고 2023나15774 판결)도 ‘유고’에 포함된다고 판단되고 있는바, 당초부터 조합장이 조합 임원으로서의 요건을 결하여 선임이 무효이므로 적법하게 직무를 수행할 수 없는 경우도 ‘유고’에 해당한다고 볼 여지가 있습니다.

합이 바람직할 것으로 사료됩니다. 즉, 도시정비법 제86조에 따라 준공인가 고시가 이루어진 후의 대지 또는 건축물의 소유권 이전 업무를 실시하는 주체도 사업시행자인 조합에 해당하므로, 소유권 이전 업무를 적법하게 처리하기 위하여는 적법한 대표권자가 조합 업무를 수행함이 안전할 것으로 보입니다.

또한, 이전고시는 관리처분계획에서 정한 바에 따라 정비사업으로 조성된 대지 또는 건축물의 소유권을 분양받을 자에게 이전하여 그 권리관계를 확정하는 절차이므로, 그 전제가 되는 관리처분계획이 적법·유효하게 성립하여 있어야 합니다. 그런데 현 조합장 선임이 무효라면, 그 후 적법한 대표권이 없는 조합장의 관여 하에 이루어진 관리처분계획 변경 결의 및 그에 기한 관리처분계획 변경인가 역시 그 효력이 부인될 가능성이 있습니다. 따라서 귀 조합은 적법한 직무대행자 또는 새로 선임된 조합장으로 하여금 관리처분계획 변경을 위한 총회를 개최하게 하고 조합원들의 결의를 받은 이후에 이전고시 절차를 진행해야 할 것입니다.

(3) 추인 결의로써 하자를 치유하지 아니하는 경우 예상되는 법적 리스크

앞서 살펴본 바와 같이, 조합 정관 및 도시정비법 규정에 따라 조합장 퇴임 전의 행위가 유효한 것으로 판단될 가능성이 있으나, 명확한 선례가 확립되어 있지 않은 이상 이에 관한 분쟁에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다.

따라서 만일 추인 결의를 통하여 하자를 치유하지 아니하는 경우, 귀 조합으로는 기독교대한감리회유지재단의 대리인인 현 조합장이 조합장으로 당선된 2024. 12. 2. 이후의 총회 결의, 계약 체결 등의 효력이 다투어짐에 따라 다수의 법률상 분쟁이 제기될 위험을 감수하여야 할 것입니다.

특히 상대방이 있는 법률행위의 경우 거래 상대방의 인식에 따라 그 유효 여부가 달리 판단될 수 있으므로, 현 조합장 당선 이후의 결의, 계약 및 그 밖의 법률행위에 관하여 일괄적으로 추인이 이루어지지 아니하는 이상 후속 법률관계가 일률적으로 정리되지 아니하는 데에 따라 혼란이 초래될 여지도 있습니다.

나아가 기존에 이루어진 결의나 계약을 기초로 후속 진행을 하고자 하는 때에 원활한 사업 수행이 이루어지지 아니할 가능성도 배제할 수 없으며, 기존 결

의나 계약에 기하여 이루어진 급부가 있다면 그 반환 등이 문제될 수도 있습니다.

4. 토론 – 기타 질의사항에 관하여

가. 조합장이 퇴임을 거부할 경우의 대응방안

귀 조합의 조합장이 퇴임을 거부하고 계속 조합장 업무를 수행할 경우, 귀 조합으로서 ① 위 조합장을 채무자로 하여 직무집행정지가처분 신청을 하고, ② 본안 소송으로 조합장지위 부존재 확인 소송 등을 제기하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다.

본안 소송은 제1심 판결시까지 최소 6개월 이상에서 1년 이상의 기간이 소요될 수 있으므로, 일반적으로는 조합장 직무집행의 정지를 구하는 가처분을 신청하고, 신청서 접수 후 2개월에서 6개월 사이에 법원 결정을 받으면 조합장 직무를 정지시킬 수 있을 것입니다.

귀 조합의 조합장 지위의 부존재는 앞서 본 바와 같이 선임결의 자체가 무효이기 때문에 발생하는 것으로서, 원칙적으로 법원 결정이나 별도 총회 결의가 없더라도 조합장의 지위는 인정될 수 없고 당연 퇴임의 효력도 이미 발생한 것으로 볼 수 있으나, 조합장이 계속 자신의 지위를 주장한다면 현실적으로 법원 결정을 받아 직무집행을 정지시키고 인수인계를 받을 수 밖에 없을 것입니다.

덧붙여, 법적인 측면에서 조합장에 대한 별도 퇴임 통지는 필요하지 아니하나, 그럼에도 퇴임 내지 조합장 직무수행 정지를 통지하고자 한다면 앞서 본 절차를 거쳐 선임된 조합장 직무대행자가 위와 같은 통지 및 요청을 하는 것이 바람직할 것입니다.

나. 현 조합장 퇴임 후 적법한 조합 운영절차

조합장이 퇴임한 이후, ① 먼저 귀 조합은 앞서 본 절차에 따라 이사회를 소집하여 조합장 직무대행자를 선정해야 할 것입니다(상근이사가 없는 경우 이사 중 최연장자가 이사회를 소집하면 되고, 최연장자가 소집 포기를 서면으로 하면 차순위 연장자가 직권으로 이사회를 소집하면 됩니다).

위 조합장 직무대행자는 정관에 근거한 것이어서 원칙적으로 기존 조합장의 모

든 권한을 행사할 수 있으나(서울고등법원 2015. 10. 23. 선고 2015 나 17274 판결 등), 조합 업무집행의 적법성을 최대한 확보하고 분쟁의 소지를 차단하지 위해서는 ② 곧바로 신임 조합장 선출을 위한 선거절차를 진행하고, 조합원 총회에서 새로운 조합장을 선임하는 것이 안전한 방안이 될 것입니다(선거 절차 및 위 조합원 총회 소집은 모두 조합장 직무대행자가 주관하여 진행하면 될 것입니다).

새로운 조합장이 선출되면, ③ 관리처분계획 변경 절차를 진행하고, 총회를 소집하여 퇴임한 조합장이 소집하거나 체결한 총회 결의 및 각 계약에 관한 추인 결의를 하고, 관리처분변경계획에 관한 결의를 하여 행정청으로부터 인가를 받고, 이후 이전고시 절차를 진행하면 될 것입니다(신규 조합장이 선출된 이후의 사업 시행 절차는 종전과 동일하므로, 특별히 유의할 사항은 없을 것입니다).

다. 대지 분양과 대토협약의 차이

구 도시정비법 제 46 조 제 2 항에서는 분양신청의 대상을 “대지 또는 건축물”로 규정하고 있는데, 위와 같은 규정만으로 대지를 분양할 수 있는 것은 아니고, 사업시행자인 조합이 대지만을 분양신청의 대상으로 지정해야 합니다.

그런데, 귀 조합의 정관 제 5 조 제 1 항은 “관리처분계획에 따라 주택이나 부대 · 복리시설을 건설하여 공급”한다고 규정하고 있고, 이에 따라 귀 조합은 분양 신청 절차에서 분양대상으로 공동주택과 근린생활시설만을 분양신청 대상으로 지정하였으며, 종교용지는 분양대상이 아닌 “정비기반시설 면적”으로 정하였을 뿐입니다.

이와 같이, 귀 조합이 종교용지를 분양대상으로 정하지 않은 이상, 기존 종교재단이 종교용지에 관한 분양신청을 할 수는 없었던 것이고, 그 대신 청산 절차의 진행을 전제로 대토협약을 체결한 것입니다.

만일 귀 조합이 종교용지를 분양대상으로 지정하고 종교재단으로 하여금 분양신청을 하도록 하였다면, 종교재단이 조합원 지위를 유지한다고 볼 수 있으나, 이러한 경우 다른 조합원들과 동일한 비례율을 적용하여 분담금을 산정하여야 하고, 건축비와 같은 추가 현금을 합의금 형식으로 지급하는 것은 허용될 수 없습니다(관리처분계획은 전체 조합원들에게 동일하게 적용되고 수립되어야 하

므로, 특정 조합원에게 비례율을 적용한 종전자산의 가치를 초과하는 금원을 지급하는 것은 도시정비법령에 위배됩니다).

결국, 종교재단에게 다른 조합원들과 달리 건축비 등을 지급하기 위해서는 분양절차가 아닌 청산절차 형식으로 진행할 수밖에 없습니다. 이에 따라 실무적으로 미리 대토협약을 체결하여 대토와 건축비 등을 청산금으로 지급하는 것으로 합의하는 것이며, 이는 해당 종교재단의 지위가 조합원이 아닌 현금청산대상자라는 것을 전제로 할 수밖에 없는 것입니다.

덧붙여, 이미 종교재단이 조합원 지위를 상실한 이상, 귀 조합의 정관을 변경하여 종교재단에게 조합원 지위를 부여하는 것은 어려울 것이고, 현실적으로 더 많은 법적 분쟁을 야기할 가능성이 높을 것으로 사료됩니다(앞서 본 바와 같이 종교재단을 조합원으로 인정하게 되면 기존의 대토합의는 인정될 수 없고 다른 조합원들과 동일하게 종전자산의 가액 비율대로 종후자산을 배분하고 분담금을 산정해야 합니다).

라. 종교재단의 조합원 지위 유지 주장에 대하여

귀 조합의 설명에 따르면, 기존 조합장은 “다른 조합원들과 유사하게 종전자산을 출자하는 대가로 대체부지, 신축 공사비, 이주비용을 제공받은 것이고, 대토합의는 분양신청 절차 이전에 체결된 것이므로, 이를 분양계약으로 볼 수 있다.”라고 주장한다는 것입니다.

그러나 앞서 상세히 살펴본 것처럼, 조합원 지위를 유지하고 분양을 받기 위해서는 도시정비법령에서 정한 분양신청 절차에서 반드시 분양신청을 해야 하는 것이며, 이러한 분양신청이 아닌 개별적인 합의를 통해 관리처분계획과 다른 기준으로 종전자산의 비율을 초과하는 금원 등을 특정 조합원에게 지급하는 것은 도시정비법령에 위배되어 허용될 수 없으며, 귀 조합의 정관에서 종교용지를 분양대상으로 삼고 있지 아니하므로 이를 분양대상으로 보는 것은 정관에 위배되는 것이기도 합니다.

아울러, 기존 조합장은 “수원시에서 조합장 선임 직후 이에 대한 인가(조합설립 변경인가로 보임)를 하였으므로 자격에 문제가 없다.”라고 주장하고 있다는 것인데, 행정청(수원시)이 인가를 하였다고 하여 무효인 총회 결의가 유효로 인정

될 수 는 없으므로, 위와 같은 주장도 전혀 타당하지 않은 것으로 판단됩니다 (수원시가 위 인가를 하면서 조합장으로 선임될 수 있는 자격 요건에 관해 심사를 하지 아니한 채 형식적으로 신고만 수리하였을 것으로 보이고, 설령 구체적인 심사를 하였다고 하더라도 행정청의 인가로 결의의 적법성이 확보된다고 볼 수도 없습니다).

덧붙여, 종교재단이 분양신청을 하지 않아 조합원 지위를 상실한 이상, 귀 조합이 조합원명부에 종교재단을 여전히 조합원으로 기재하고, 해당 종교재단의 대리인이 의결권을 행사하고 조합장으로 선임되었다고 하더라도, 위와 같은 사정만으로 조합원 지위가 회복된다고 볼 수는 없습니다.

이상의 내용을 귀 조합의 업무에 참고하시기 바랍니다. 끝.